

1079481-98.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Repetição de indébito

Magistrado: Maria Gabriella Pavlóoulos Spaolonzi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 13ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... no sentido de que 'o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos', razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, 'a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria'. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

13ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1079481-98.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1079481-98.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Repetição de indébito

Requerente:

Hospital Alvorada Taguatinga Ltda (Next Hospital Santo Amaro - Antigo Hospital Alvorada Santo Amaro) e outros

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Gabriella Pavlóoulos Spaolonzi

Vistos.

AMICO SAÚDE LTDA, por si e por suas filiais E OUTROS, nomeados na petição inicial, devidamente qualificados e representados, ajuizaram a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária e obrigacional cumulada com repetição de indébito em desfavor de Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Aduzem, em síntese, que são sociedade empresárias que exercem atividade hospitalar, médica, medicina diagnóstica, dentre outras, com consumo ininterrupto de energia elétrica, figurando como contribuintes do ICMS. Uma vez que os Requerente são adquirentes contumaz de energia elétrica e, em razão da dimensão de seu consumo, celebram contratos diferenciados junto às empresas concessionárias de energia elétrica, a partir dos quais parcela de sua distribuição de energia elétrica mensal refere-se ao consumo medido em KWh, e a outra parcela à demanda por potência, medida em KW. Alega que há períodos em que os Requerentes consomem quantidades menores de energia, razão pela qual a quantidade de demanda contratada disponibilizada pela concessionária nem sempre é integralmente utilizada.

Esclarecem que nas faturas mensais de energia elétrica, constam a incidência

de ICMS sobre a energia consumida e também sobre o valor pago sob o título de demanda contratada. Aduz que a ré está exigindo ICMS sobre base de cálculo superior àquela permitida pela legislação pátria, vez que o tributo não está sendo cobrado apenas sobre o valor da mercadoria/serviço efetivamente utilizado, mas integralmente sobre a demanda contratada por potência, o que afrontaria entendimento pacificado no enunciado de Tema de Repercussão Geral n. 176 do STF e Súmula 391 do STJ.

Desse modo, requer: (i) a concessão de tutela de evidência, para determinar a suspensão de exigibilidade do ICMS incidente sobre demanda contratada, de modo a evitar a prática de atos de execução/cobrança de tais valores; (ii) a procedência total da ação, para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as Requerentes e o Estado Requerido quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre a totalidade do contrato de demanda de potência de energia elétrica não utilizada, bem como impedindo-se a imposição de quaisquer medidas coercitivas relacionadas à sua cobrança, com declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade de exigência de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica. Pugna, ainda, pela condenação da ré à restituição e/ou compensação às empresas filiadas do autor dos valores indevidamente recolhidos, nos últimos cinco anos anteriores à distribuição do feito, acrescidos de correção monetária e juros legais, nos termos da legislação vigente, que será apurado ao final da demanda. Juntou documentos às fls. 22/1764.

Decisão de fls. 1765/1769 deferiu a tutela de urgência para tutela de urgência para resguardar ao polo ativo o direito de efetuar o pagamento do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, excluindo-se da base de cálculo a quantia de energia elétrica não consumida, porque indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada e não utilizada.

Citada, a ré apresentou defesa na forma de contestação (fls. 1778/1798). Suscitou preliminar de ilegitimidade da substituída no pedido de restituição de valores, uma vez que o custo de energia elétrica foi incorporado ao preço de mercadorias e serviços oferecidos aos consumidores. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança, sustentando a improcedência do pedido, ao argumento de que o autor parte de premissa equivocada, pois afirma que os Requerentes estão recolhendo ICMS sobre energia elétrica que não consumiram, quando na realidade, a energia elétrica que está sendo cobrada foi-lhes integralmente fornecida. Salienta que a demanda contratada não é energia elétrica posta à disposição da contratante, mas sim, fornecida, e como tal, legitimamente cobrada. Aponta que "demanda contratada" não equivale a reserva de energia não consumida, mas sim caracteriza grandeza de potência com fornecimento assegurado para regular desenvolvimento das atividades das contratantes, ora Requerentes, o que legitima a cobrança do tributo, observado o enunciado de Súmula n. 391 do STJ. Subsidiariamente, defendeu que a repetição de indébito deve ser condicionada à comprovação documental dos recolhimentos tributários apontados nos autos, evocou aplicação de regra de prescrição quinquenal e regras de juros e correção monetária em eventual condenação. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Instados sobre provas (fl. 1807), a ré requer o julgamento antecipado da lide (fls. 1811). A parte autora não especificou provas. Houve réplica (fls. 1813/1833).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

O julgamento antecipado é medida que se impõe, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, porque a questão de mérito é exclusivamente de direito. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com pedido de Repetição de Indébito, na qual a parte autora objetiva o reconhecimento da ilegalidade da incidência de ICMS, com o qual vem arcando, sobre o fornecimento de energia elétrica no "contrato de reserva de demanda ou potência", devendo a cobrança ficar adstrita apenas a energia que foi consumida e integralmente fornecida e não sobre a demanda contratada. Aduz o autor que a ré está embutindo indevidamente no valor da cobrança

do ICMS energia elétrica que não foi consumida, baseada exclusivamente na existência de "contrato de demanda reservada ou de potência de energia elétrica" firmado entre os autores e a concessionária de energia.

Desta feita, insurge-se o autor em razão do fato das Requerentes estarem arcando com o pagamento de ICMS embutido na conta de fornecimento de energia elétrica, decorrente de contrato de reserva de demanda ou potência, base de cálculo que considera equivocada, na medida em que estão pagando por energia que não consumiram efetivamente.

Inicialmente, necessária a apreciação da questão preliminar suscitada pela Requerida. Afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa da autora, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.299.303/SC, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973, firmou entendimento segundo o qual o consumidor detém legitimidade ativa para postular a repetição de valores recolhidos a título de ICMS incidente sobre energia elétrica demanda contratada e não utilizada.

Nesse precedente, foi firmado o Tema n.º 537, que estabeleceu: "diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada".

E não há que se falar em relação de substituição na hipótese fática apresentada sub judice, caracterizando-se as Requerentes como consumidoras finais na contratação de fornecimento de energia elétrica.

Assim, afastada a ilegitimidade ativa alegada em preliminar, passo à análise do mérito.

Em que pesem as razões da requerida Fazenda do Estado, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante julgamento afetado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 63, REsp 960.476/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.03.2009), que firmou entendimento no sentido de que "a simples formalização de contrato de fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria, razão por que não pode o ICMS incidir sobre a denominada 'demanda contratada'. O tributo incide apenas sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor." Nesse sentido, o Recurso Especial n.º 343.952/MG, REL. MIN. ELIANA CALMON, j. 05.02.2002; Recurso Especial n.º 647.553/ES, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, j. 05.04.2005; e Recurso Especial n.º 960.476/SC, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 11.03.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973.

Transcrevemos:

"TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. 1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que 'o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos', razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, 'a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria'. Afirma-se, assim, que 'o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrada no estabelecimento da empresa'. 2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que 'não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência'. Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. 3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de

faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. Estes julgados do Superior Tribunal de Justiça resultaram na Súmula 391, segundo a qual "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, INC. II, CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. ICMS. CRITÉRIO DE DEMANDA RESERVADA OU CONTRATADA. TRIBUTO QUE SOMENTE INCIDE SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA.

I - Quedou-se o recorrente agravante em afirmar, genericamente, ter a Corte ordinária deixado de se pronunciar sobre dispositivos legais, sem demonstrar por que esta análise seria imprescindível à solução da controvérsia, de modo a viabilizar, ao menos em tese, outro resultado ao julgamento. Assim sendo, evidente incidir a Súmula n. 284/STF, a inviabilizar o especial, no particular. II - Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "o fato gerador do ICMS dá-se com a efetiva saída do bem do estabelecimento produtor, a qual não é presumida por contrato em que se estabelece uma demanda junto à fornecedora de energia elétrica, sem a sua efetiva utilização" (REsp nº 825.350/MT, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 26.05.2006, p. 250). III - Outro precedente citado: REsp nº 806.281/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 11.05.2006, p. 171. IV - Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no REsp nº 855.929/SC Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO 1ª Turma Data do Julgamento: 19.09.2006).

E, sobre o tema, cumpre salientar que a matéria sub judice já foi pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 391: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Assim, para fins de incidência de ICMS, a energia elétrica é qualificada como mercadoria, conforme exegese do artigo 155, inciso II e § 3.º da Constituição Federal. Com isso, o fato gerador, representativo da circulação da mercadoria pela saída do estabelecimento do fornecedor opera no momento da efetiva utilização da energia elétrica pelo consumidor final.

Logo, apenas a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor importa em circulação de mercadoria, a autorizar a incidência do ICMS. Desta forma, a reserva de potência não pode ser admitida para a incidência do ICMS, por falta de circulação da mercadoria, de modo que o tributo não incidirá sobre os valores relativos à demanda contratada ou reservada de energia elétrica, porque a saída da mercadoria do estabelecimento do fornecedor não se presume pelo contrato celebrado entre as partes. Assim, a mera disponibilização de potência e, daí, a garantia reservada de potência em si, não justifica a incidência do ICMS, nem a inclusão do valor desta garantia na base de cálculo de mencionado imposto.

No mesmo sentido está a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça Paulista:

TRIBUTÁRIO - ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária c.c. repetição de indébito - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO - Inocorrência - Entendimento firmado pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que o consumidor final tem legitimidade para propor ação relativa a ICMS incidente sobre energia elétrica - Preliminar rejeitada - MÉRITO - Reserva de demanda não consumida - O ICMS deve incidir apenas sobre a demanda de potência efetivamente utilizada de energia elétrica - Decisão do STJ no julgamento do REsp nº 960.476/SC - Súmula nº 391 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012175-54.2017.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/04/2020;

Data de Registro: 27/04/2020)

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ENERGIA ELÉTRICA - ICMS Incidência sobre a energia efetivamente consumida e não sobre a demanda contratada Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça Súmula 391 do C. STJ Sentença reformada. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 0022094-06.2010.8.26.0320; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2014; Data de Registro: 04/06/2014)

Assim, sendo ilegítima a exação, devem ser restituídos os valores indevidamente exigidos a esse título, observada a prescrição quinquenal, interregno cujos comprovantes de pagamentos serão oportunamente apresentados, sendo de rigor a procedência da ação.

Sobre o valor a restituir cumpre que se adicione correção monetária desde o desembolso, que propriamente nada acrescenta ao capital, apenas preservando o valor da moeda, de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP até o trânsito em julgado. A partir de então, deverá ser aplicada a taxa SELIC (que abrange os juros de mora e correção monetária), conforme decidido pelo C.STJ no Recurso Especial nº 1.111.189/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 19) e consoante art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ ("Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença").

Isto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, e extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do Diploma Processual Civil, para reconhecer e declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre reserva de demanda de energia elétrica não utilizada, devendo a requerida abster-se de novas cobrança, e que o valor pago a mais seja retirado, definitivamente, nas próximas faturas de consumo de energia elétrica das Requerentes, tornando definitiva a tutela de evidência deferida nestes autos.

Condena-se, ainda, a requerida a restituir os valores indevidamente cobrados das Requerentes, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação. Sobre os valores incidirão juros e correção monetária nos termos supra fixados. Pela sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo do valor da condenação a ser apurado quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC).

Sentença sujeita ao reexame necessário.

P.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA